

1531151-09.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves
Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... é a jurisprudência do E. TJSP:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença procedente. Recurso defensivo.

Preliminares: 1.1. Ilícitude probatória: a) ilicitude da busca pessoal e b) violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Absolvição por atipicidade da conduta. Desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. Alegação de atipicidade da conduta por violação aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531151-09.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531151-09.2019.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3134347/2019 - 01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI MOREIRA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

DAVI MOREIRA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Consta que no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Santa Joana D'Arc, número 02, Morro São Bento, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Termo circunstanciado (fls. 01/04). Auto de constatação preliminar (fls. 05). Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06). Laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 28/30).

A denúncia foi recebida em 17/12/2020 (fls. 70).

O acusado foi citado (fls. 96/97) e notificado (fls. 146/147), apresentando resposta à acusação (fls. 132/137) e defesa prévia (fls. 149/154).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, também em alegações finais, por sua vez, reiterou os termos da defesa prévia, pugnano pela absolvição do réu, pela atipicidade da conduta, pela inimputabilidade do acusado e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, ou, subsidiariamente, pela aplicação de pena alternativa de advertência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 01/04), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 28/30) e pela prova oral produzida durante o processo.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha MARCOS ROBERTO NEVES, policial civil, disse que, quando em operação de rotina, chega a levar em torno de 25 a 30 pessoas para a delegacia. Afirmou que, por conta disso, não se recorda do réu, já que as operações que realiza acontecem todos os meses, e o fato se passou há muito tempo.

A testemunha MARCOS PRADO, policial civil, afirmou que se recorda dos fatos por ter lido o Boletim de Ocorrência, mas não reconhece o acusado e nem o ocorrido, por ter acontecido em uma operação.

O acusado, ouvido em Juízo, disse que os fatos são verdadeiros. Disse ser usuário de crack, maconha e cocaína, há 15 anos. Afirmou que já foi internado na clínica CEAD, em Peruíbe. Aduziu que, quando os policiais chegaram, já havia consumido parte do entorpecente que possuía.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Inicialmente, não merece acolhimento a tese defensiva de atipicidade da conduta do acusado e de inconstitucionalidade do delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

O fato de a matéria estar sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e de haver votos favoráveis à inconstitucionalidade do artigo não o torna inconstitucional. Anoto, ainda, que não há que se falar em atipicidade da conduta de porte de drogas para uso próprio, permanecendo, sob a égide do princípio da legalidade, descrita como fato típico a conduta praticada pelo réu e expressa no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJSP:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença procedente. Recurso defensivo.

Preliminares: 1.1. Ilícitude probatória: a) ilicitude da busca pessoal e b) violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Absolvição por atipicidade da conduta. Desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. Alegação de atipicidade da conduta por violação aos direitos fundamentais da intimidade e da vida privada.

Pedidos subsidiários: a) readequação do aumento operado na segunda fase da dosimetria da pena; b) fixação do regime inicial diverso do fechado; c) aplicação da detração penal. 1. Preliminares. 1.1. Ilícitude da busca pessoal. Configuração de fundadas razões para realização do procedimento de busca pessoal. Precedentes.

Ação dos policiais militares realizada em contexto de flagrante delito durante regular atividade de policiamento ostensivo. Ilegalidade não reconhecida. 1.2.

Alegação de violação ao direito ao silêncio. Confissão informal quanto ao tráfico de drogas. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norte-americana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios.

Inadmissibilidade da prova ilícita. 1.3. Exceções à prova ilícita por derivação.

Ilícitude da confissão informal do réu que não é capaz de contaminar outros elementos probatórios. Apreensão das drogas decorrente de busca pessoal lícita no acusado. Fonte independente preexistente. Desconsideração das referências feitas pelos policiais à confissão informal. Subsistência dos demais relatos não

relacionados com a prova ilícita. Desconexão causal. Réu que admitiu a posse das drogas. Aplicação do art. 157, do Código de Processo Penal que se impõe. Precedentes da Suprema Corte norte-americana reconhecidos pela jurisprudência nacional e incorporados na legislação. 2. Do mérito. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas. Negativa do réu. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. Da tipicidade da conduta. 3.1. Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Recurso Extraordinário nº 635.659 ainda pendente de julgamento. Norma penal que tem como objeto a tutela da saúde pública. Precedentes. 3.2. Afastamento da tese de atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato. Precedentes. 4. Dosimetria. 4.1. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Réu reincidente. 4.2. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se as preliminares arguidas. (TJSP; Apelação Criminal 1504072-96.2021.8.26.0073; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2022; Data de Registro: 05/06/2022)". Grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Porte de entorpecente para uso próprio - Materialidade e autoria comprovadas - Inviabilidade de se afastar a configuração da hipótese prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 para absolver o réu pela alegada inconstitucionalidade - Norma legal hígida que integra o ordenamento jurídico vigente - Absolvição pelo princípio da insignificância - Impossibilidade - Quantidade que não revela a irrelevância da conduta e já serviu como um dos subsídios para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio - Delito de perigo abstrato - Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores - Condenação mantida - Sanção adequada diante das peculiaridades do caso concreto - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000019-35.2017.8.26.0511; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)". Grifei.

Vale ressaltar, ainda, o entendimento do Desembargador ZORZI ROCHA, exposto no julgamento da Apelação n.º 0000127-78.2016.8.26.0050, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09.03.2017: "Desde a vigência da Lei n.º 6368/76, a posse de entorpecente para uso próprio passou a ser considerada crime, e assim continua sendo com a vigência da Lei n.º 11.343/2006, que em seu artigo 28, expressa previsão legal. A alteração contida na atual Lei n.º 11.343/2006 (artigo 28), quanto ao preceito secundário do crime em questão - deixando de estabelecer pena privativa de liberdade e multa como era no art. 16 da Lei n.º 6368/76 - não significou descriminalização da conduta, pelo contrário, o que ocorreu foi, na verdade, uma ampliação das hipóteses de conformação típica, e um considerável abrandamento punitivo, dando lugar às penas educativas de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas ou cursos".

Assim, sendo a saúde pública o bem jurídico tutelado pela norma, com a posse ou porte do entorpecente, mesmo que para uso próprio, o bem jurídico continua sendo afetado o que torna necessária a sua proteção.

Desta forma, não há que se falar em conduta atípica ou inconstitucional, com relação ao delito de posse de entorpecentes para consumo próprio.

Outrossim, apesar de o próprio acusado afirmar que estava sob o efeito de drogas no momento da prática do delito, para o reconhecimento das mencionadas causa de excludente de culpabilidade e causa de diminuição de pena, a embriaguez ou a intoxicação causada por drogas deve decorrer de caso fortuito ou força maior.

Desta forma, verifico que a culpabilidade do agente é clara, não havendo que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a intoxicação do acusado, causada por drogas, ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior.

Nesse passo, deve-se ressaltar que o uso de entorpecentes e/ou a embriaguez voluntária não são causas de exclusão da culpabilidade. Apenas a doença mental provocada pela dependência, comprovada em incidente de insanidade mental, pode afastar a imputabilidade, o que não ocorreu no presente feito.

Desta forma, verifico que a culpabilidade do agente é clara, não havendo que se falar em inimputabilidade.

Também não merece acolhimento a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de droga encontrada em poder do acusado era ínfima.

Nesse passo, ressalto que tal princípio não se aplica ao crime de porte de entorpecente, haja vista que o consumo de drogas ilícitas é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas, também, pelo perigo que este consumidor gera para a sociedade, ao estimular o narcotráfico e, conseqüentemente, diversos outros crimes.

Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 37094 MG 2013/0118921-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)". Grifei.

Quanto à destinação do entorpecente, observando a quantidade, maneira de acondicionamento e as circunstâncias de sua apreensão, não resta dúvidas de sua destinação ao uso pessoal.

Nesse sentido, a prova é firme em confirmar que o acusado foi surpreendido pelos policiais enquanto portava drogas em local onde comumente se comercializa entorpecentes, sendo que em seu poder foram localizadas duas cápsulas plásticas contendo cocaína, ressaltando-se que o próprio réu confessou a prática delitiva. Desta forma, as provas carreadas aos autos são robustas e claras, autorizando o desate condenatório e relação ao crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Observando a quantidade apreendida e a inexistência de circunstâncias desfavoráveis aos réus, nos termos do inciso I, do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, o que faço para CONDENAR o acusado DAVI MOREIRA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Defiro ao réu o direito de recorrer me liberdade.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a condição de beneficiários da Justiça Gratuita.

P.I.C.

Santos, 21 de junho de 2022.

LEONARDO DE MELLO GONÇALVES

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA